

1503044-28.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado, a condenação do réu Gabriel pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

De outra banda, quanto ao acusado Felipe não há nos autos elementos suficientes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503044-28.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503044-28.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

FELIPE COSTA BACELAR e GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, GABRIEL trazia consigo, para fins de tráfico, uma sacola plástica contendo 51 porções de maconha, 117 porções de cocaína e 24 pedras de crack, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e FELIPE tinha consigo um rádio comunicador. Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar. A denúncia foi recebida e os réus foram citados.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e uma testemunha do Juízo. Ao final, foram os réus interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da ação para condenação dos réus nos

termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, outrossim, pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa do acusado Felipe pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime a ele imputado para a conduta prevista no artigo 37 da Lei de Drogas. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional.

A Defesa do acusado Gabriel requereu sua absolvição, por falta de provas e, subsidiariamente, formulou pedidos quanto à fixação da pena e do regime prisional.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo pericial, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito, porém apenas por parte do acusado Gabriel.

Interrogados em Juízo, os réus negaram a prática do crime.

Felipe disse que estava a caminho da casa da mãe de seu filho, onde está instalado seu comércio, e viu pessoas correndo. Contou que não correu e foi abordado. Disse que nada havia consigo e nada foi localizado no local em que estava, que nem mesmo era um ponto de venda de drogas. Contou que o primeiro policial depoente havia seguido um indivíduo, mas nenhuma pessoa foi detida. Disse que, então, foi realizada pesquisa por seu e, constatado possuir antecedentes, foi indagado, respondendo ao policial que possuía ocupação regular. Alegou que foi conduzido até outro local em viatura, onde viu Gabriel abordado. Disse que não conhecia Gabriel anteriormente aos fatos e não estava próximo a ele antes da abordagem. Contou que não viu drogas com os policiais e nada viu no local onde Gabriel estava detido. Não recordou o que Gabriel falou sobre os fatos.

Gabriel disse havia passado a noite fora de casa e, porque precisava trabalhar naquela data, foi ao ponto de tráfico de drogas para adquirir uma porção de cocaína com os cinco reais que tinha em seu bolso. Disse que entregou o dinheiro ao traficante e, enquanto aguardava ser servido, policiais chegaram ao local e o traficante correu. Alegou que foi agredido pelos policiais e questionado por eles sobre a identidade do indivíduo que estava realizando o tráfico, mas disse nada saber e que ali estava apenas para comprar droga. Contou que havia consigo somente maço de cigarro e isqueiro. Disse que não presenciou a abordagem do corréu Felipe e não teve contato com ele, pois não o conhecia e nada sabia sobre ter ele envolvimento com drogas. Declarou que o corréu Felipe foi conduzido à delegacia em viatura diversa e não conversaram sobre os fatos. Disse que fazia tratamento em razão do uso de entorpecente antes de ser preso e trabalhava quando era chamado por Eduardo.

Contudo, a negativa do acusado Gabriel e a versão por ele apresentada não são críveis em face do restante das provas produzidas durante o processo.

A testemunha policial militar Bruno Damas dos Santos, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, quando viu os acusados correrem ao notar a presença da equipe policial. Narrou que o acusado Felipe tentou esconder-se atrás de uma pilastra dentro dos prédios situados no local, mas foi abordado e, em sua posse, preso a um cordão, foi localizado um rádio comunicador. Consignou que permaneceu naquele mesmo local onde estava a viatura, com o acusado Felipe já contido, enquanto seu parceiro de farda foi ao encalço do outro indivíduo que havia corrido. Relatou que seu parceiro retornou com o corréu Gabriel, informando ter encontrado no casado dele as drogas que foram apreendidas. Declarou que, informalmente, o acusado Felipe admitiu a participação no tráfico de drogas, recebendo o valor de R\$80,00 para comunicar a chegada de viaturas aos indivíduos que vendiam drogas, e disse não conhecer o corréu Gabriel que, por sua vez, alegou que estava naquele local apenas para comprar entorpecente e disse não conhecer Felipe. Narrou que não foi localizado rádio comunicador na posse do acusado Gabriel. Disse que, em regra, indivíduos correm em tais locais quando da chegada da equipe policial e consignou que, naquela data, viu os réus e viu correria, tendo

visto o acusado Felipe correndo para dentro do prédio e o corréu Gabriel correndo para a parte de trás, onde há um campo de futebol e outros prédios. Não conhecia os acusados anteriormente aos fatos.

A testemunha policial militar Marcos Vinicius de Paula Leite, também ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas quando viu os dois réus. Consignou que havia outras pessoas no local, mas somente os acusados correram quando da chegada de sua equipe policial. Relatou que o acusado Felipe foi logo abordado e, em sua posse, foi encontrado um rádio comunicador, enquanto o corréu Gabriel conseguiu empreender fuga. Declarou que seu parceiro de farda permaneceu naquele local com o acusado Felipe já abordado, enquanto foi ao encalço do acusado Gabriel e conseguiu abordá-lo, encontrando no bolso de sua blusa de moletom uma sacola contendo maconha, cocaína e crack. Relatou que, indagados sobre os fatos, o acusado Gabriel alegou, informalmente, que a droga não era de sua propriedade e que ele estava no local apenas para comprar entorpecente, nada dizendo sobre a sacola encontrada com ele, enquanto o acusado Felipe admitiu que recebia R\$80,00 para avisar, pelo rádio comunicador, sobre a aproximação de viaturas policiais. Consignou que somente foi apreendido rádio comunicador com o acusado Felipe. Não conhecia os réus anteriormente aos fatos.

A testemunha do Juízo Eduardo Ribeiro de Oliveira Filho disse que não presenciou a prisão dos acusados. Declarou que havia chamado o acusado Gabriel para trabalhar naquela data na cozinha de um restaurante, pedindo que ele se apresentasse ao trabalho às 11 horas, porém ele não o fez. Soube, então, pela genitora de Gabriel, que este havia sido detido com drogas. Disse que o trabalho do acusado Gabriel era um "extra" e que o havia chamado na noite anterior ao dia em que ocorreram os fatos. Declarou que o corréu Gabriel já havia trabalhado consigo em outro restaurante e nunca havia faltado quando o convocava para o serviço. Disse que tinha ciência de que o acusado Gabriel fazia uso de entorpecente.

Pelas circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente, evidencia-se a realização do tráfico de drogas pelo acusado Gabriel, não havendo dúvidas sobre sua conduta criminosa no que se refere a este delito, diante das provas produzidas. A palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e coerente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem dos réus e a localização e apreensão da droga com o acusado Gabriel, não restou abalada.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida

por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme,

segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço da Defesa do acusado Gabriel em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos dos policiais colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial e a localização do entorpecente com o corréu Gabriel.

As testemunhas policiais bem explicaram em Juízo exatamente o que presenciaram na data dos fatos e como se deu toda a ação policial, descrevendo em detalhes terem visto os acusados Gabriel e Felipe correndo quando da aproximação da viatura no local dos fatos, e dilucidaram, de forma pormenorizada, a conduta de cada acusado e a ação realizada por cada um dos agentes de segurança durante a abordagem.

Veja-se que as testemunhas ressaltaram ter abordado primeiro o acusado Felipe, em posse de quem encontraram um rádio comunicador, e ambos os policiais consignaram que, tendo o corréu Gabriel empreendido fuga, somente o policial Marcos Vinícius foi ao seu encalço, logrando êxito em contê-lo e encontrando, ainda em sua posse, no bolso de sua blusa de moletom, uma sacola contendo considerável quantidade de entorpecentes variados.

Asseverou a testemunha policial Bruno que não presenciou a abordagem do corréu Gabriel, pois manteve-se na contenção do acusado Felipe e na guarda da viatura policial, porém tomou ciência da localização e apreensão de entorpecentes na posse daquele.

A questão pertinente ao número de indivíduos que teriam corrido quando da chegada dos policiais ao local dos fatos, como aduzido pela Defesa do acusado Gabriel, em nada infirma a prova amealhada nos autos, uma vez que ambas as testemunhas afirmaram ter visto os dois acusados correndo e ter sido o corréu Gabriel detido em poder da sacola onde estavam armazenadas as drogas.

De outro lado, o depoimento da testemunha de defesa Eduardo não abalou em nada os demais elementos probatórios constantes dos autos quanto à prática do tráfico de drogas pelo corréu Gabriel.

Ressalte-se que Eduardo nada presenciou e foi informado da prisão de Gabriel, por estar com drogas, pela genitora deste, após ele não ter se apresentado ao restaurante para um trabalho “extra”, para o qual o havia chamado.

Assim, a negativa do acusado Gabriel restou isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Malgrado a constatação de lesão corporal no laudo pericial encartado às fls. 53/54, saliente-se que não se apurou nestes autos as circunstâncias em que ela ocorreu e as alegadas injustas agressões cometidas pelos policiais contra o acusado Gabriel não infirmam a prova coligida aos autos que traz a certeza quanto à sua autoria no crime de tráfico de drogas.

Consigne-se que não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o

réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas. Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão apresentada pelo acusado Gabriel, em Juízo, sobreponha-se aos depoimentos dos policiais encarregados de suas prisões, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito de tráfico de drogas.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu Gabriel é de fato traficante.

Dessa forma, por todo o conjunto probatório amalhado, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado Gabriel e a localização do entorpecente por ele trazido, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu Gabriel deriva da natureza, variedade e da grande quantidade e demais circunstâncias em que as drogas foram com ele apreendidas.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Passo à dosagem da pena.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado, a condenação do réu Gabriel pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

De outra banda, quanto ao acusado Felipe não há nos autos elementos suficientes para embasar sua condenação.

Conforme se verifica da prova colhida em Juízo, os policiais militares avistaram os acusados Gabriel e Felipe correrem quando da chegada da viatura policial.

Relataram que, feita a abordagem de Felipe, com ele foi encontrado um rádio comunicador e que, questionado, informalmente admitiu a participação no tráfico de drogas, atuando no alerta a indivíduos que vendiam as drogas sobre a chegada de policiais.

Todavia, em que pese ser possível que o acusado Felipe estivesse no local concorrendo com o corréu Gabriel para a prática do tráfico de drogas exercido por este, certo é que, no presente caso, a efetiva participação de Felipe neste delito não restou bem caracterizada.

Note-se que as testemunhas policiais consignaram ter visto os acusados correndo, mas não forneceram maiores detalhes sobre terem visto os corréus juntos anteriormente à fuga, nem houve qualquer outra demonstração do vínculo havido entre eles para a prática do tráfico de drogas naquela data.

Com Felipe foi apreendido um rádio comunicador que, embora pudesse ser utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas naquele local, não caracteriza, por si só, o tipo penal que lhe foi imputado.

Assim, em relação ao corréu Felipe, para se lançar uma condenação, é imprescindível a certeza ampla de ser ele coautor do crime ou ter ele concorrido para o crime que lhe foi atribuído. Se houver qualquer dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se impõe, porquanto a liberdade de uma pessoa não pode ser coarctada sem que a acusação seja comprovada por provas exatas e seguras.

Frise-se que sua inocência não é patente.

Todavia, diante desse quadro probatório e havendo sérias dúvidas no que pertine à participação no crime descrito na denúncia, a absolvição de Felipe é medida que se impõe, pois antes absolver provável culpado a condenar inocente.

Procedente em parte a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas cometido pelo réu Gabriel.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena. Assim, fixo sua pena-base em de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. Destaque-se, ainda, que, o uso de máscaras de proteção facial em espaços de acesso público localizados no território estadual, como medida para conter a disseminação da COVID-19, conforme disposto no Decreto nº 65.897 de 30 de julho de 2021 do Estado de São Paulo, permaneceu vigente até o dia 08 de setembro de 2022, quando tais medidas foram liberadas por meio do Decreto nº 67.096. Saliente-se, ainda, que, embora sem revogação expressa do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública neste estado, deve-se considerar que as medidas de contenção contra o avanço do novo coronavírus permaneceram vigentes até 08 de setembro deste ano de 2022 quando, por parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo, verificou-se possível esta flexibilização dos regramentos.

A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal em mais 1/6, a qual resta fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor já estabelecido.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da considerável quantidade da droga apreendida.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do *ne bis in idem* a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura *bis in idem* a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,

julgado em 16/03/2017 , PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Ademais, a grande quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal;

2. ABSOLVER o réu FELIPE COSTA BACELAR, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação que lhe foi feita de haver praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao réu GABRIEL o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social. Destaca-se, ainda, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi o acusado GABRIEL proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu GABRIEL na prisão em que se encontra.

Diante da absolvição do acusado FELIPE, expeça-se Alvará de Soltura clausulado em seu favor.

Indefiro o pedido para a extração de cópia dos autos e remessa à Polícia Civil para instauração de inquérito na forma requerida pelo Ministério Público, uma vez que a Constituição Federal não recepcionou a primeira parte do inciso II do artigo 5º do Código de Processo Penal.

Evidentemente, sob pena de se perder a imprescindível imparcialidade inerente ao juiz, não pode ele deliberar sobre a opinio delicti (cuja titularidade foi entregue pela Constituição Federal de 1988 ao Ministério Público) requisitando a instauração de inquérito policial, indiscutivelmente uma atividade persecutória.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POR FORÇA DE REQUISICÃO DO JUIZ. INC. II DO ART. 5º DO CPP NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

1. Não pode o juiz investigar, função própria da autoridade policial, não pode e não deve, também, requisitar abertura de inquérito policial. A primeira parte do inciso II do art. 5º do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal, que alçou o sistema acusatório à sua posição máxima, ao entregar tão-só ao Ministério Público a função de acusar, como se pode observar da leitura do art. 129, VIII, da Constituição Federal. Nemo iudex sine actore (Não há juiz sem autor) ou ne procedat iudex ex officio (o juiz não pode proceder sem provocação da parte). 2. O juiz não pode e não deve deliberar sobre a opinio delicti (opinião, ponto de vista sobre o delito). Há a perda da imprescindível imparcialidade do juiz ao deliberar sobre a opinio delicti, requisitando a instauração de inquérito policial, por tratar-se de uma atividade persecutória. 3. No presente caso, no entanto, o juiz que requisitou o inquérito não vai presidir o processo, haja vista que foi dele afastado. A proibição de o juiz requisitar o inquérito é para preservar sua imparcialidade." (TRF, 1ª Região, HC 64844 MT 2009.01.00.064844-9, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ TOURINHO NETO, Julgamento em 23 de Novembro de 2009, Publicação em 04/12/2009 e-DJF1 p.214)

Dessa forma, caberá ao próprio Ministério Público providenciar o necessário para a concretização de seu requerimento.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 19 de dezembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA